

1501822-64.2021.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 - Relator(a): Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

2ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Sala 05/07, Alemães - CEP 13417-100, Fone: (19)3433-4177, Piracicaba-SP - E-mail: piracicaba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501822-64.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2322539/2021 - 02º D.P.

PIRACICABA, 21630279 - 02º D.P. PIRACICABA, 4677/21/518 - 02º D.P. PIRACICABA, 2322539 - 02º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MANOEL PEDRO DE LIMA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

*

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 10 dias do mês de março de 2022, à hora designada, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, apresentaram-se a Exma. Sra. Dra. FLAVIA DE CASSIA GONZALES DE OLIVEIRA, MMª Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, Dr. Rafael Augusto Pressuto e o(a) Defensor(a) Público(a), Dr(a).Daniela Batalha Trettel. Apresentados o(a)(s) acusado(a)(s) MANOEL PEDRO DE LIMA e as testemunhas arroladas em comum pelas partes: Thamires Zurdo Moraes Marçura e Gustavo Phatricy Nicolau Silva.

Fica consignado que foi assegurado o direito de entrevista do(a)(s) acusado(a)(s) com seu(sua)(s) defensor(a)(es), em reunião virtual apartada, no estrito cumprimento do artigo 185, § 5º, do C.P.P., tendo a MM Juíza feito ao(a)(s) acusado(a)(s) a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal.

INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foi(ram) colhido(s) o(s) depoimento(s) da(s) testemunha(s) (Thamires e Gustavo) pelo sistema virtual e, após, o interrogatório do réu.

Em seguida, pela MM Juíza foi deliberado:

“Não havendo mais provas a serem produzidas, encerro a instrução, determinando às partes que passem aos debates orais:

Dada a palavra ao(à) ilustre representante do Ministério Público, manifestou-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza, MANOEL PEDRO DE LIMA foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pois, no dia 26 de novembro de 2021, por volta de 12h20min, na esquina da Avenida Rio das Pedras com a Rua Pedro Ferraz Pacheco, Bairro Piracicamirim, nesta cidade e comarca, trazia consigo e mantinha sob guarda ou depósito, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 20 (vinte) eppendorfs contendo 'cocaina', com o peso líquido de 4,6g (quatro gramas e seis decigramas), e 10 (dez) porções de "crack", substância derivada da 'cocaina', com peso líquido de 1,2g (um grama e dois decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O processo teve andamento regular. Devidamente notificado a fls. 97, o réu apresentou defesa prévia a fls. 101/104. A denúncia recebida a fls. 121/123. Durante a instrução, o réu foi interrogado e foram ouvidas as testemunhas arroladas.

É a síntese necessária.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, fotografia de fls. 11, laudo de constatação de fls. 13/17 e laudo químico-toxicológico definitivo de fls. 114/116.

A autoria do crime descrito na denúncia restou também suficientemente comprovada. Com efeito, a policial militar Thamires Zurdo Moraes Marçura na Delegacia de Polícia, relatou: “que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido pela venda de drogas, momento em que visualizaram um indivíduo trajando blusa cinza e calça jeans que entregou algo que aparentava ser dinheiro a outro indivíduo que vestia roupa preta, o qual, após avistar a viatura, se evadiu. Contou que realizaram o retorno pelo quarteirão, quando, no mesmo local, constataram que o indivíduo, vestido com blusa cinza e calça jeans ainda continuava lá. Diante da atitude suspeita, resolveram abordá-lo. Em busca pessoal, foram localizados consigo 05 microtubos de substância aparentando ser cocaína e 05 pedras de substância aparentando ser crack, além da quantia de R\$ 22,00. Questionado, o indivíduo identificado como Manoel Pedro de Lima confessou que estava traficando no local, bem como apontou onde havia mais quantidade de entorpecente escondido, qual seja, em um monte de areia próximo e que o indivíduo visto anteriormente esteve no local para comprar drogas, sendo o dinheiro localizado oriundo da venda de entorpecentes. Assim, em diligências no local apontado, foram encontrados 15 microtubos plásticos de cocaína, além de outras 05 pedras de crack, idênticos aos localizados com o indiciado. Diante dos fatos, deram voz de prisão ao indivíduo, que apresentou resistência e tentou empreender fuga, sendo necessário a utilização de algemas para resguardar a integridade do indivíduo e da equipe. Por fim, declarou que não conhecia o indivíduo anteriormente” (fls. 03).

Em juízo, a policial militar prestou depoimento no mesmo sentido. Esclareceu que, durante patrulhamento, visualizaram o acusado transacionando algo com outra pessoa. Pouco depois, realizaram a abordagem, ocasião em que apreenderam, em seu poder, 5 porções de "crack" e 5 porções de maconha. Depois disso, o acusado indicou o local em que estava o restante das drogas, em uma pilha de areia, que foi posteriormente apreendido, tratando-se de 15 porções de cocaína e 5 de "crack". Informou que viu o réu recebendo dinheiro na referida transação. O réu confessou o tráfico na ocasião. Informou que o local é conhecido como ponto de tráfico, ficando próximo ao "Bar do Pantera". Relatou que a entrada do bar fica na Avenida Rio das Pedras, sendo que o acusado foi surpreendido na rua lateral do estabelecimento.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Gustavo Phatricy Nicolau Silva, tanto na fase policial (fls. 04), quanto em juízo. O policial acrescentou

que, com o réu, também foi encontrada a quantia de R\$ 22,00. Consignou, também, que o réu confessou o tráfico e indicou o local em que estavam escondidas as drogas. O réu, na fase inquisitorial, optou pelo silêncio (fls. 05).

Em juízo, o acusado confessou a prática do tráfico de drogas. Alegou que comercializava entorpecentes para manter o próprio vício.

Dessa forma, analisando-se detidamente a prova pericial e oral produzida nos autos, verifica-se a imputação restou devidamente comprovada, na medida em que o conjunto probatório impõe a condenação, não apenas sob o enfoque da prova técnica produzida, mas, também, diante dos testemunhos dos guardas municipais.

No que tange à palavra dos agentes públicos, importante observar que foi corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos, mormente pela apreensão das drogas em poder do acusado.

Portanto, merece valor o depoimento dos agentes públicos diante da coerência e harmonia com o restante do acervo probatório, além do que, sequer possuíam motivos para incriminá-lo.

Com efeito, “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/64), de maneira que é “inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT 530/372 e, no mesmo sentido, STRTJ 68/54).

Desse modo, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos, a forma de acondicionamento das substâncias, tudo confirmando pelos depoimentos judiciais, não há dúvidas de que as drogas se destinavam à comercialização.

Assim, comprovadas a materialidade e autoria delitiva a condenação é medida que se impõe.

No que tange à dosimetria da pena, entendo que a natureza da droga – cocaína e crack –, por seu elevado poder viciante e por ser devastadora para a saúde, deve ensejar a fixação da pena base acima do mínimo, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Na segunda fase, de rigor o reconhecimento da agravante da reincidência específica (CP, art. 61, inciso I), conforme certidão de fls. 34/35. Presente, ainda, a atenuante da confissão, devendo prevalecer, contudo, a reincidência específica, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Na terceira fase de dosimetria, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem valoradas.

Anoto que o acusado não faz jus a causa de diminuição de pena, do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em razão da reincidência, inclusive específica.

Por derradeiro, a reincidência específica bem justifica a fixação do regime fechado. Ademais, a recidiva, assim como o quantum da reprimenda, inviabiliza a concessão de penas alternativas.

Requeiro, por fim, seja decretado o perdimento do valor apreendido com o acusado, com fulcro nos artigos 61 e 63, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer a condenação do réu MANOEL PEDRO DE LIMA, nos termos da denúncia, julgando o pedido totalmente procedente.

Dada a palavra ao(à) nobre defensor(a) do(a)(s) acusado(a)(s), manifestando-se sua Excelência nos seguintes termos:

"MM.Juíza,

Manoel Pedro de Lima foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia (fls. 89-90), no dia 26 de novembro de 2021, por volta de 12h20min, na esquina da avenida Rio das Pedras com a rua Pedro Ferraz Pacheco, bairro Piracicamirim, nesta cidade e comarca de Piracicaba/SP, Manoel trazia consigo e mantinha sob guarda ou depósito, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 20 (vinte) eppendorfs contendo “cocaína”, com o peso líquido de 4,6g (quatro gramas e seis decigramas), e 10 (dez) porções de “crack”, substância derivada da “cocaína”, com peso líquido de 1,2g (um grama e dois decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar.

Ainda de acordo com a inicial, policiais militares, em patrulhamento, avistaram o réu entregando um objeto a um transeunte que fugiu ao notar a viatura. Os policiais abordaram o réu e, em revista pessoal, encontraram em poder dele cinco tubos contendo "cocaína" e cinco porções de "crack", além de R\$22,00. Sob a indicação do réu, escondido em um monte de areia, encontraram o restante dos entorpecentes. Aos policiais militares, confessou a prática delitiva.

Interrogado em solo policial, o réu exerceu o seu direito constitucional ao silêncio (fls. 5).

Thamires Zurdo Moraes Marçura, policial militar, narrou que: "estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido pela venda de drogas, momento em que visualizaram um indivíduo trajando blusa cinza e calça jeans que entregou algo que aparentava ser dinheiro a outro indivíduo que vestia roupa preta, o qual, após avistar a viatura, se evadiu. Realizaram o retorno pelo quarteirão, quando, no mesmo local, constataram que o indivíduo vestido com blusa cinza e calça jeans ainda continuava lá. Diante da atitude suspeita, resolveram abordá-lo. Em busca pessoal, foram localizados consigo 05 microtubos de substância aparentando ser cocaína e 05 pedras de substância aparentando ser crack, além da quantia de R\$ 22,00. Questionado, o indivíduo identificado como Manoel Pedro de Lima confessou que estava traficando no local, bem como apontou onde havia mais quantidade de entorpecente escondido, qual seja, em um monte de areia próximo e que o indivíduo visto anteriormente esteve no local para comprar drogas, sendo o dinheiro localizado oriundo da venda de entorpecentes. Assim, em diligências no local apontado, foram encontrados 15 microtubos plásticos de cocaína, além de outras 05 pedras de crack, idênticos aos localizados com o indiciado. Diante dos fatos, deram voz de prisão ao indivíduo, que apresentou resistência e tentou empreender fuga, sendo necessário a utilização de algemas para resguardar a integridade do indivíduo e da equipe. Não conhecia o indivíduo" (fls. 3).

No mesmo sentido a versão apresentada pelo policial militar Gustavo Phatricy Nicolau Silva. (fls. 4).

Às fls. 34-35, juntada certidão de objeto e pé que indica a reincidência do requerido (autos n.º 1500971-93.2019.8.26.0599 - tráfico privilegiado - trânsito em julgado para a Defesa em 4/10/2021).

- DA PRODUÇÃO DE PROVAS NOS AUTOS

A materialidade do delito se comprova pelo auto de exibição e apreensão de fls. 9-10, fotografia de fls. 11, laudo de constatação de fls. 13-17 e laudo de exame definitivo de fls. 114-116.

Com relação à autoria, em audiência de instrução foram colhidos os seguintes elementos:

a) Ouvida, inicialmente, Thamires Zurdo Moraes Marçura, policial militar. Estava em patrulhamento no local, viram duas pessoas trocando algo, objeto e dinheiro. Um estava de blusa cinza e outro de blusa preta. Fizeram a volta e somente Manoel permanecia ali. Revistado, com ele foram localizadas 5 porções de maconha e 5 de crack. Tinha também R\$20,00. Posteriormente, no entorno foram localizadas outras 15 porções de crack (ou de cocaína) e 5 de maconha (ou de crack) em uma pilha de areia, ao lado de onde ele estava. Manoel era o indivíduo de blusa cinza e estava pegando o dinheiro. Somente viram a mão dele e, depois, pegando o dinheiro. Ele confessou informalmente a traficância e indicou onde estavam as outras drogas. O local é conhecido como ponto de venda de trocas. Há um bar próximo (Bar do Pantera) onde ocorre traficância constante. Não conhecia o réu. Foi a primeira vez que o abordou. Ele estava na esquina do bar, na calçada. O bar fica na esquina, a entrada é na Rua Rio das Pedras, mas o réu estava na rua lateral. Não sabe dizer se o bar estava cheio ou vazio. O réu teria comentado com o parceiro que estava passando por dificuldades.

b) Na sequência, foi ouvido o policial militar Gustavo Phatricy Nicolau Silva. Estavam em patrulhamento e viram Manoel recebendo dinheiro de outro indivíduo. O outro rapaz fugiu. Abordado Manoel, com ele localizaram 5 pedras de crack, 5 pinos de cocaína e R\$22,00. Indagado, ele confessou a traficância e indicou onde estavam as outras drogas (15 pinos de cocaína e 5 pedras de crack). Era um monte de areia.

O próprio réu desenterrou a droga e entregou aos policiais. Posteriormente, ele foi conduzido à delegacia. O local é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Não conhecia o réu.

c) Por fim, foi interrogado o réu Manoel Pedro de Lima. Confirmou as informações dos policiais. Estava traficando para sustentar o vício. Passou por 7 internações em razão da dependência química, a última deles no Instituto Bairral. É usuário de cocaína, crack, maconha e álcool. Recaiu em setembro de 2021. Conseguiu ficar sem usar de janeiro a setembro. A mãe tem mais de 70 anos e o irmão é esquizofrênico.

Dependem dos seus cuidados.

- DAS ALEGAÇÕES RELATIVAS À DOSIMETRIA DA PENA

Considerando a confissão e a sua consonância com as demais provas do processo, a defesa passa a discorrer acerca da pena.

a) Da pena-base

Na remota hipótese de condenação, de rigor a fixação da pena-base em seu mínimo legal: as consequências e a culpabilidade são normais para o caso, não justificando uma reprovação penal maior.

b) Da segunda fase da dosimetria

Na segunda fase, a agravante da reincidência deverá ser compensada com a atenuante da confissão, mantendo-se a pena no mínimo legal.

c) Da incidência da causa de diminuição prevista pelo art. 41 da Lei de Drogas

Caso se tome como verdadeira a versão policial, tem-se que o réu acabou por indicar o local onde se encontrava a maior parte da droga, permitindo a sua apreensão.

Dispõe o artigo 41 da Lei de Drogas que "o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços".

Não obstante a Lei nº 11.343/2006 não defina o que é "produto do crime", ela o diferencia da ideia de "proveito" previsto no art. 60 desse diploma normativo, que seria o benefício econômico advindo o tráfico, por exemplo, o dinheiro.

Guilherme de Souza Nucci estabelece, especificamente no contexto do art. 41 da Lei de Drogas, que "produto do crime" é a droga e não o lucro ou vantagem que a sua inserção no mercado acarretaria: "Menciona a norma do art. 41 o produto do delito e não o proveito. Logo, é a substância entorpecente, que necessita ser recuperada, total ou parcialmente [...]" (NUCCI, 2017, p. 979).

Assim, uma vez compreendido que o produto do crime é a substância entorpecente propriamente dita, uma vez que o acusado tenha voluntariamente colaborado para sua localização, terá ele direito à redução da pena.

Nesse ponto, cabe esclarecer que os requisitos do art. 41 da Lei de Drogas devem ser interpretados de forma alternativa, em conformidade com o instituto da colaboração premiada previsto na Lei de Organização Criminosa, aplicando-se a minorante nos casos de efetiva contribuição para localização das drogas OU de identificação de coautores ou partícipes.

Isso porque a cumulatividade dos requisitos a um só tempo (i) feriria o princípio da proporcionalidade ao não valorar o efetivo auxílio prestado pelo acusado à autoridade policial; (ii) retiraria a efetividade da norma legal quando o tráfico não fosse praticado em concurso de pessoas; (iii) colidiria com os objetivos do legislador ao prever a colaboração como meio de produção de provas e (iv) representaria indevida confusão entre os institutos da delação premiada e da colaboração premiada, na medida em que aquele é espécie deste último, que tem incidência mesmo que não se delate qualquer comparsa.

Assim, de forma a conferir racionalidade e eficácia à norma contida no art. 41 da Lei de Drogas, mostra-se necessário adotar uma interpretação sistêmica e teleológica do instituto da colaboração premiada, analisando-o à luz da normativa prevista na Lei de Organizações Criminosas.

O artigo 4º da Lei nº 12.850/13 prevê cinco formas alternativas – segundo o caput do artigo – por meio das quais o(a) acusado(a) poderá colaborar com a investigação e com o processo: (i) identificar os demais coautores e partícipes da organização criminosa e as infrações penais por eles praticadas; (ii) revelar a estrutura

hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa; (iii) prevenir as infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa; (iv) recuperar total ou parcialmente o produto ou o proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa e (v) localizar o paradeiro de eventual vítima com sua integridade física.

De acordo com o regime jurídico da Lei de Organizações Criminosas, é suficiente, portanto, que apenas uma dessas situações esteja preenchida para que o(a) acusado(a) faça jus à redução da pena.

Para Claudia Lima Marques, entre a Lei de Drogas e a Lei de Organizações Criminosas há um diálogo de influências recíprocas sistemáticas, existente quando os conceitos estruturais de uma lei são influenciados por outra. “É a influência do sistema especial no geral e do geral no especial, um diálogo de duplé sens (diálogo de coordenação e adaptação sistemática)” (MARQUES, 2007, p. 91).

Destarte, adotando-se uma interpretação sistêmica e teleológica do art. 41 da Lei de Drogas, em consonância com a normativa geral posteriormente trazida pela Lei de Organizações Criminosas, faz-se imprescindível admitir a alternatividade dos requisitos da colaboração premiada, aplicando-se o redutor de pena quando o auxílio do(a) acusado(a) resultar na recuperação total ou parcial da droga, independentemente da delação de outros agentes.

No presente caso, verifica-se dos depoimentos prestados pelos policiais, tanto em sede policial quanto em juízo, que a colaboração do réu foi imprescindível para a localização da maior parte dos entorpecentes, sendo certo que o referido auxílio foi por ele prestado de forma voluntária. Portanto, ele fazendo jus à causa de diminuição de pena expressa no referido artigo.

De mais a mais, com relação ao quantum da minorante, é necessário que seja aplicado no patamar máximo, de 2/3 (dois terços) porque se não fosse a colaboração voluntária do réu possivelmente os entorpecentes não teriam sido apreendidos.

- DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao regime inicial, em atenção ao disposto no art. 33, § 3º, diante da quantidade pena a ser aplicada e das circunstanciais judiciais, inexistindo fundamentação concreta a recomendar o regime mais gravoso (Súmulas 718 e 719 do STF; Súmula 440 do STJ), de rigor a aplicação do regime diverso do fechado.

Adicionalmente, para a fixação do regime inicial, não poderá ser observado o disposto no art. 1º, § 2º, da LCH, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade pelo STF, exercendo sua função típica de guardião da Constituição e, por isso, proferindo uma decisão de observância obrigatória por todo o Judiciário (CF, art. 102 c. c/ art. 927 do CPC).

- DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Finalmente, deve ser assegurado ao acusado o direito de apelar em liberdade. De acordo com o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, ao proferir uma sentença de condenação, “O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”. Ademais, a decisão pela manutenção da prisão preventiva deve ser concreta, cabendo ao julgador “[...] indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (CPP, art. 315, § 2º). Com efeito, uma vez encerrada a instrução, ainda que se entenda pela manutenção da prisão preventiva anteriormente exposta, a decisão deve ser concretamente fundamentada, visto que ainda vigente o estado de inocência (CF, art. 5º, LVII; CADH, art. 8.2).

No mais, no atual cenário, qualquer decisão que determina o recolhimento de alguém ao cárcere ou a manutenção de uma prisão anteriormente decretada deve ser ponderada à luz da crise sanitária causada pelo COVID-19. Considerando a situação emergencial de saúde pública decorrente do coronavírus (COVID-19), somada ao fato de que estabelecimentos em que há aglomeração de pessoas privadas de liberdade são muito mais suscetíveis à disseminação de doenças virais, e visando a reduzir ao máximo os riscos advindos de uma possível contaminação por coronavírus, principalmente dos sujeitos ainda protegidos pela presunção de inocência e acusados de crime não considerados graves, mostra-se imperiosa a concessão do direito de apelar em liberdade, caso o acusado seja condenado.

Em seguida pelo(a) MM.Juiz(a) foi dito o seguinte:
Passo a proferir a seguinte sentença:

VISTOS.

MANOEL PEDRO DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 26 de novembro de 2021, por volta de 12h20, na esquina da Avenida Rio das Pedras com a Rua Pedro Ferraz Pacheco, Bairro Piracicamirim, nesta cidade e comarca, trazia consigo e mantinha sob guarda ou depósito, para entregar ou fornecer ao consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, 20 (vinte) eppendorfs contendo 'cocaína', com o peso líquido de 4,6g (quatro gramas e seis decigramas), e 10 (dez) porções de "crack", substância derivada da 'cocaína', com peso líquido de 1,2g (um grama e dois decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo a denúncia, policiais militares, em patrulhamento, avistaram o réu entregando um objeto a um transeunte que fugiu ao notar a viatura. Os policiais abordaram o réu e, em revista pessoal, encontraram em poder dele cinco tubos contendo "cocaína" e cinco porções de "crack", além de R\$22,00. Sob a indicação do réu, escondido em um monte de areia, encontraram o restante dos entorpecentes.

Aos policiais militares, o réu confessou a prática delitiva. Na Delegacia de Polícia, permaneceu silente (fls. 05).

Considerando as circunstâncias da prisão, a apreensão de dinheiro, a diversidade e forma de embalagem de entorpecentes, é certo que o réu os trazia consigo, guardava e tinha em depósito com a finalidade de comércio ilícito.

A denúncia foi oferecida (fls. 88), sendo determinada a notificação do réu para oferecer defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 91/92).

O réu foi notificado (fls. 97) e apresentou defesa prévia, na qual requereu a revogação da prisão preventiva e alegou inocência (fls. 101/104).

A denúncia foi recebida, designando-se audiência virtual (fls. 121/123). O réu foi citado (fls. 137).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, sendo o réu interrogado.

Encerrada a instrução, em memoriais, as partes se manifestaram.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

1) Da materialidade

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, na fotografia de fls. 11, no laudo de constatação de fls. 13/17, bem como no exame químico-toxicológico de fls. 114/116, segundo o qual foi detectada a presença de cocaína, nas substâncias apreendidas.

2) Da autoria

A autoria ficou demonstrada nos autos.

Na fase investigativa, o réu permaneceu calado (fls. 05).

Em Juízo, o réu afirmou que confessou a acusação. Estava vendendo, para seu uso. É usuário de drogas e já fez vários tratamentos. No total, esteve internado por 07 vezes. Estava vendendo drogas, para custear seu próprio uso. Faz uso de cocaína, maconha, crack e recaiu em setembro de 2021. Tem vários problemas de saúde. Tem mãe idosa e irmão esquizofrênico. Mora com eles e os ajuda nos afazeres diários.

A autoria restou comprovada nos autos, conforme se verifica das provas. Vejamos.

A policial militar feminina Thamires Zurdo Moraes Marçura relatou que estava em patrulhamento, quando avistaram dois indivíduos, um passava um objeto e o outro entregava dinheiro. Fizeram o retorno e só o réu estava ali, a pessoa que viu recebendo o dinheiro. Em busca pessoal, seu parceiro encontrou com ele 05 porções de maconha e 05 porções de crack, além de dinheiro. Indagado, o réu confessou que estava no tráfico e ainda indicou uma pilha de areias, nas proximidades, onde havia mais entorpecente. Nesse local, encontraram mais 15 porções de cocaína e 05 porções de crack. O local é conhecido como ponto de venda de drogas, fica perto do Bar do Pantera. O réu estava na esquina do bar, na calçada. Foi o próprio réu quem pegou o

restante de drogas na pilha de areia. O bar e suas portas ficam na avenida e o réu estava na rua lateral. O local é comum para tráfico. Viram o réu entregando algo e recebendo dinheiro. O réu tinha dinheiro no bolso. O réu vestia roupas comuns para o local que estava. Acha que o réu disse que estava passando por dificuldades e, por isso, estava no tráfico.

No mesmo sentido, o depoimento do também policial militar Gustavo Phatricy Nicolau Silva, segundo o qual estavam em patrulhamento, quando passaram pelo cruzamento e viram dois indivíduos, o réu recebia um dinheiro de outro rapaz. Suspeitaram dos fatos e abordaram apenas o réu. Quando avistaram a viatura eles, se dissiparam, cada um para um lado. Em revista pessoal, com o réu encontraram 05 pedras de crack e 05 pinos de cocaína, além de R\$ 22,00. Indagaram o réu sobre a droga, ele confessou o tráfico e indicou que no monte de areia guardava o restante da droga. Ele mesmo foi até o monte de areia e pegou o restante da droga: 15 pinos de cocaína e 05 pedras de crack. O local é conhecido como ponto de venda de drogas. Não conhecia o réu. O réu não tinha aspecto de morador de rua, as vestimentas eram normais. O réu não tinha cachimbo ou petrecho de uso de drogas com ele. A primeira questão a ser analisada nos autos é o envolvimento do réu com a droga apreendida.

O réu, que só se manifestou em Juízo, alegando que estava vendendo drogas, para sustentar seu próprio vício.

Os policiais militares narraram que estavam em patrulhamento por local conhecido como ponto de venda de drogas, quando avistaram dois indivíduos, um entregando alguma coisa e outro e dele recebendo dinheiro. O que entregou o dinheiro, ao ver a viatura, fugiu do local. Os policiais fizeram a volta e, quando retornaram, o indivíduo que tinha recebido o dinheiro continuava no ponto de venda de drogas e, por isso, foi abordado. Em revista pessoal, com o réu, encontraram 05 microtubos de cocaína e 05 pedras de crack, além da quantia de R\$ 22,00. Questionado, o réu confessou que estava praticando o tráfico de drogas, indicou o local onde estava o restante da droga e ele mesmo pegou, do monte de areia nas proximidades, o restante da droga apreendida. Nesse monte de areia, havia mais 15 microtubos de cocaína e 05 pedras de crack, embalados de maneira idêntica àqueles que estavam na posse do réu. Com efeito, temos uma única versão sobre os mesmos fatos, no sentido de que o réu estava na posse de parte da droga e o restante estava em sua guarda.

Mesmo que não houvesse confissão, considerando que o réu foi visto em ponto de venda de drogas fazendo contato com terceira pessoa e, mesmo após o retorno da viatura encontrava-se no mesmo lugar, bem como que a maior parte da droga foi encontrada em local por ele apontado, entendo que a palavra dos policiais militares deve se sobrepor à palavra do réu.

Ainda que assim não fosse, a palavra dos policiais militares, como funcionários públicos que são, tem validade como prova, a menos que haja alguma prova de que têm interesse no resultado da demanda penal. Ressalto que o depoimento dos agentes policiais foi firme, unânime e inquestionável.

Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...) (AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). (...) IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (...) (HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo

entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018 - grifei).

Ressalto, por outro lado, que os policiais militares não conheciam o réu e não teriam motivo para prejudicá-lo injustamente.

Assim, a distinção cabível, neste momento processual, é sobre a existência do dolo que comprova a traficância.

O elemento subjetivo do tipo, como diz respeito à intenção do agente, contida em seu interior, não é perceptível logo de início, mas sim aferível por meio das circunstâncias externas que acabam por traduzir o interior do agente. Entende a jurisprudência:

"O aferidor, que marca as fronteiras entre os tipos penais previstos nos artigos 12 e 16 da Lei 6368/76, reside na finalidade com que a erva é guardada, transportada, adquirida ou tida em depósito. Se para exclusivo uso próprio o delito é o do artigo 16 e, caso contrário, se configura do artigo 12" (TJRS - Ver. 695102699 - Rel. José Eugênio Tedesco - RJTJRS 175/54).

"Para a caracterização do crime de narcotráfico, como em relação aos demais delitos punidos na Lei 6368/76, atender-se-á à quantidade da substância apreendida, ao local e condições em que se desenvolveram a ação criminosa, às circunstâncias da prisão, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, tal como dispõe o artigo 37, da referida lei" (TJRS - Ver. - Rel. Rubens Rebelo Magalhães - RJTJRS 74/11).

No caso dos autos, o réu alegou que a droga era mesmo para a venda. A prova confirma que a destinação do entorpecente era o consumo de terceiras pessoas. Inicialmente, o réu foi visto em ponto de venda de drogas, entregando dinheiro a terceira pessoa. Além disso, depois que avistou a viatura, o réu permaneceu no mesmo lugar, sendo abordado. Ora, se usuário fosse, o réu teria deixado o ponto de venda de drogas, sem mais retornar, no entanto, manteve-se no seu posto de trabalho.

Abordado, com o réu, havia pouca quantidade de drogas, mas no monte de areia por ele mesmo indicado, havia o restante. Essa situação é comum entre os traficantes, que permanecem com pouca quantidade de entorpecente em seu poder, para despistar eventuais policiais que lhe abordem.

A quantidade da droga (20 microtubos de cocaína e 10 pedras de crack) não é comumente encontrada com usuários, na rua.

Além da droga, com o réu, havia dinheiro, cuja origem lícita não foi comprovada. Informalmente aos policiais militares e em audiência, o réu confessou a mercancia ilícita.

Assim, o local da abordagem, a situação fática presenciada pelos policiais, o fato de o réu manter-se no ponto de venda após avistar a viatura, a quantidade de drogas e sua forma de embalagem, a existência de dinheiro, a confissão, enfim, tudo confirma que a droga tinha como destinação o consumo de terceiras pessoas.

Ressalto que ainda que mesmo que o réu seja usuário de entorpecente, a traficância não fica afastada, uma vez que várias pessoas nessas condições acabam por vender

entorpecentes até mesmo para sustentar o seu vício ou pagar dívida de drogas. Além disso, a dependência refere-se à imputabilidade e não à caracterização do delito. Diz a jurisprudência:

"A condição de dependente químico não elide a prática do delito de tráfico de drogas." (TJAC - Processo: EI 10414920108010001 AC 0001041-49.2010.8.01.0001 - Relator(a): Pedro Ranzi - Julgamento: 27/04/2011 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: 30/04/2011).

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE. DESCABIMENTO. Acusada que admitiu a venda de entorpecentes. Apreensão de grande quantidade de "crack", aliada às demais circunstâncias do flagrante, que impedem a conclusão de que os entorpecentes se destinassem ao consumo próprio. FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE. A condição de dependente químico está relacionada ao conceito de imputabilidade (pressuposto de aplicação da pena) e não interfere na subsunção do fato ao tipo penal. Condição de toxicômano que não elide a conclusão de que a ré se dedicava à narcotraficância. Figura do usuário-traficante amplamente admitida pelos tribunais. Defesa, ademais, que sequer se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada dependência química da acusada. Condenação pelo crime de tráfico mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO." (TJSP - Processo: APL 182718720088260451 SP 0018271-87.2008.8.26.0451 - Relator(a): Amado de Faria - Julgamento: 13/09/2012 - Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal - Publicação: 20/09/2012).

"A simples alegação de o agente ser viciado em drogas não tem o condão de desclassificar a conduta, mormente se surpreendido na posse de grande quantidade de entorpecente, de molde a evidenciar finalidade de venda" (TJRN, Ap. 00.001954-2, Câm. Crim., j. 1º.06.2001, rel. Juiz João Rebouças, V.U., RT 796/688).

"A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando à última, de maior gravidade" (TJSP - HC 42.229-3 - Rel. Onei Raphael - RJTJSP 101/498).

"Tráfico de entorpecente - Grande quantidade da droga apreendida em poder do acusado, evidenciadora do propósito de comercialização - Desclassificação para uso, em razão da dependência, inadmissível - Inteligência dos artigos 12 e 16 da Lei n.º 6.368/76" (TJMT - AC 565/86 - Rel. Mauro José Pereira - RT 620/331).

A condenação, assim, é de rigor.

3) Da delação premiada

Aduziu a Defesa que os requisitos do artigo 41 da Lei nº 11.343/06 devem ser interpretados de maneira alternativa, de forma que se o agente voluntariamente colaborar com a indicação do esconderijo da droga ou com a identificação de coautores, a causa de diminuição deve ser reconhecida.

Dispõe o artigo 41 da Lei nº 11.343/06: "Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços".

Inicialmente, há se se questionar se, no caso de tráfico de drogas, o produto do crime é o entorpecente.

Existem decisões no sentido de que a droga é o próprio objeto material do crime de tráfico, de forma que sua recuperação não serviria para preencher o requisito legal da delação premiada:

"(...) De outro lado, a delação premiada normalmente precedida da confissão espontânea, inexistente nos autos, tem cabimento quando há identificação dos demais coautores e partícipes do crime (inexistente na espécie), bem como à recuperação total ou parcial do seu produto (também inexistente no caso concreto). Assim, a causa de diminuição de pena não é aplicável. Não houve qualquer identificação de comparsa, tampouco qualquer colaboração dele para fins de recuperação de produto do tráfico de drogas, que é o lucro ou bens materiais outros da mercancia decorrentes. Destarte, não ocorrido delação, mas encontro da droga por ação policial, realmente não há razão para se premiá-lo (...)" (TJSP; Apelação Criminal 1530044-59.2019.8.26.0228; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito

Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/06/2021; Data de Registro: 09/06/2021).

Por outro lado, também é imprescindível que o delito seja cometido em concurso de agentes:

"Ademais, incabível a aplicação do artigo 41 da Lei nº 11.343/06, porque o acusado deveria, no mínimo, que ter colaborado com a investigação, ou com o processo criminal, a ponto de delatar coautores ou partícipes, contribuindo, desse modo, com o desmantelamento de associação criminosa ou, ao menos, com o combate ao tráfico local. Nesse ponto, destaque-se o posicionamento jurisprudencial majoritário no sentido de que o instituto em questão só tem lugar quando o delito é cometido por mais de um agente. Como já se decidiu: "A conduta praticada pelo paciente não se subsume à prevista para a aplicação do art. 41 da Lei 11.343/06, ao contrário do que quer fazer crer o impetrante; isso porque, a previsão formulada nesse artigo traz a figura da delação premiada, somente sendo possível a sua incidência quando, na prática de qualquer dos delitos previstos na Lei 11.343/06, o agente perpetrar a conduta em concurso de pessoas, o que não ocorreu na hipótese dos autos" (HC nº 99.422/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, j. 12/08/2008, DJe 22/09/2008). (...) (TJSP; Apelação Criminal 1500388-16.2020.8.26.0198; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franco da Rocha - Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/06/2021; Data de Registro: 15/06/2021)

Por fim, entendo que a intenção do legislador, no caso do artigo 41 da Lei nº 11.343/06 não foi dar opção quanto à conduta do agente, mas sim exigir que ele aponte coautor e auxilie na recuperação do produto do crime, ambos cumulativamente. Nos ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, volume 1, 8ª Edição, Editora Forense, pag. 377/378), são requisitos para a aplicação do benefício: a) haver um inquérito, com indiciamento, e/ou um processo contra o autor da delação; b) prestação de colaboração voluntária, independentemente de espontaneidade, porém livre de qualquer coação; c) concurso de pessoas em qualquer dos delitos previstos na Lei 11.343/2006 e; d) recuperação total ou parcial do produto do crime, anotando que estes requisitos são cumulativos.

E se o artigo 4º da Lei nº 12.850/13 prevê formas alternativas por meio das quais o agente poderá colaborar com a investigação e se beneficiar da redução, o artigo 41 da Lei nº 11.343/06 prevê cumulatividade dos requisitos.

Assim já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS Nº 670912 - RJ (2021/0169153-9) [...] Do mesmo modo, não merece prosperar o pleito defensivo de aplicação da causa de diminuição do artigo 41, da Lei 11.343/06, que dispõe: [...] A delação premiada se aplica a quem, confessando, forneça dados imprescindíveis para o desenrolar da investigação policial ou do processo criminal, sendo indispensável o auxílio das informações na identificação de coautores e na recuperação do produto do crime, cumulativamente. Na presente hipótese, o ora apelante foi preso em flagrante, não tendo participado das investigações, tampouco colaborado para a prisão de coautores, pelo que, impossível o reconhecimento da mencionada atenuante. Vale destacar que, o fato de o agente apontar, no momento da sua prisão em flagrante, aonde se encontrava parte do material entorpecente apreendido, por si só, não viabiliza o reconhecimento da referida benesse"(e-STJ, fls. 25-26). Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para reduzir a sanção final do paciente para 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, mantido o regime fechado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 01 de setembro de 2021. Ministro Ribeiro Dantas Relator (STJ - HC: 670912 RJ 2021/0169153-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 03/09/2021 - grifei).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E RECEPÇÃO. Recurso defensivo. PRELIMINARES. PRETENDIDA OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO APÓS PARECER DA PGJ. Impossibilidade. Ministério Público em 2º Grau que atua como custos legis. Precedentes doutrinário e jurisprudencial. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP), CPP, ART. 28-A, § 14. Aventada nulidade. Inocorrência. ANPP que deve ser aplicado na fase pré-processual.

Parecer da PGJ nesse sentido. MÉRITO NÃO CONTESTADO. DOSIMETRIA. Penas criteriosamente estabelecidas. Inaplicabilidade do art. 41 ("delação premiada"), assim como do redutor do art. 33, § 4º em maior extensão e das benesses do CP, art. 44. Regime modificado ao semiaberto nos termos do HC nº 596.603/SP do STJ. PROVIMENTO PARCIAL. [...] Contrariamente ao alegado pela defesa, inviável a aplicação do instituto da "delação premiada", positivada na Lei nº 11.343/06, art. 41. Conforme ensinamento do Professor GRECO FILHO, Vicente : "a colaboração deve ser com a investigação policial ou o processo criminal clara e diretamente dirigida às autoridades do inquérito ou do processo criminal" (Tóxicos - Comentários à Lei nº 11.343/2006, 13ª Edição, 2009, Ed. Saraiva, p. 215). Isso porque, na hipótese, não houve qualquer colaboração. PATRÍCIA apenas admitiu a propriedade exclusiva das drogas, não indicando qualquer outro detalhe ou até mesmo possível fornecedor. (TJ-SP - APR: 15005615220188260540 SP 1500561-52.2018.8.26.0540, Relator: Eduardo Abdalla, Data de Julgamento: 08/09/2021, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/09/2021 - grifei).

E, no caso em concreto, embora o réu tenha mencionado onde estava a droga, seria possível aos policiais a localizarem, no monte de areia que estava ao lado do réu, não havendo certeza de que não encontrariam o entorpecente. A eficiência da delação, portanto, é questionável.

Ausentes, portanto, ambos os requisitos da delação premiada previstos no artigo 41 da Lei nº 11.343/06, impossível seu reconhecimento.

4) Do dispositivo e da pena

Na dosagem da pena, devem ser levadas em consideração as diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Pleiteou o Ministério Público o aumento da pena, em razão da qualidade da droga apreendida. Entendo, contudo, que o crack e a cocaína, ainda mais na quantidade apreendida, é entorpecente corriqueiro e que não desponta maior periculosidade pelo agente, de forma que não serve para aumentar a pena, na primeira fase de sua dosimetria.

Assim, o réu não possui antecedentes criminais, de forma que sua pena-base deve ser calculada no mínimo legal: reclusão de 05 anos e 500 dias-multas.

Nem se diga que a atenuante da confissão não pode ser compensada pela agravante da reincidência, uma vez que ambas são de natureza subjetiva, dizem respeito ao réu e, portanto, são de mesma grandeza.

Sobre o assunto:

(...) 4. Prevalece na Terceira Seção desta Corte Superior o entendimento de que é possível a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, por constituírem circunstâncias igualmente preponderantes, devendo o julgador atentar para as singularidades do caso concreto. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 558.930/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).

(...) 7. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESp n. 1.341.370/MT, sob o rito do art. 543-C, c/c o § 3º, do CPP, consolidou entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013). (...) (AgRg no AREsp 1637220/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020).

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. FALSA IDENTIDADE E FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL. INEXISTÊNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA.

DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.

COMPENSAÇÃO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. "É firme o entendimento deste Superior

Tribunal de Justiça no sentido de que o exame de corpo de delito, direto ou indireto, é indispensável para a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo, no delito de furto, consoante disposto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, c/c o art. 158, do Código de Processo Penal" (AgRg no RESp

1838301/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em

07/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Hipótese em que não foi realizado o exame pericial, nem tampouco foi apresentada justificativa para a sua inexistência, impondo-se o

afastamento da qualificadora. Precedentes. 3. A Terceira Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que, por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. 4. Ainda que se trate de reincidência específica, pode ela ser integralmente compensada com a atenuante relativa à confissão espontânea. Precedentes. 5. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus por se afigurar manifestamente incabível e concedeu a ordem de ofício para afastar a qualificadora de rompimento de obstáculo e para determinar a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante de confissão espontânea. 6. Agravo desprovido. (AgInt no HC 509.333/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020).

(...) 3. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EREsp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, firmou o entendimento segundo o qual a atenuante da confissão espontânea, uma vez que compreende a personalidade do agente, é circunstância deve ser compensada com a agravante da reincidência, igualmente preponderante. 4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 1608521/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020).

Aliás, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tem, em tese repetitiva: "Confissão espontânea (atenuante) compensa a reincidência (agravante) na dosimetria" (Tema: 585).

Assim, a reincidência (Certidão de fls. 34/35